

1501389-94.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... consolidado do STJ, vejamos:

"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APROFUNDADA INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. CONSUNÇÃO PELO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA. CRIMES AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

2ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1501389-94.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501389-94.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DE MOURA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

PEDRO HENRIQUE DE MOURA e RYAN MATOS SILVÉRIO, já devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", em concurso material com o artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque em data incerta, mas até o dia 26 de maio de 2022, na Rua Diamante, nº 151, Bairro Capela, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que em 26 de maio de 2022, por volta das 17h45min, na Rua Diamante, nº 151, Bairro Capela, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, teriam mantido em depósito 80 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso bruto aproximado de 35,2g (trinta e cinco gramas e dois decigramas); 118 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 185g (cento e oitenta e cinco gramas); 14 porções de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecido como maconha, com peso bruto aproximado de 74,9g (setenta e quatro gramas e nove decigramas), para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (pág. 129/130).

Os réus foram citados (pág. 222/223 e 224/225) e apresentaram a defesa (pág. 183/187).

Na resposta à acusação, argumentou a Defesa dos réus, que irá se manifestar sobre o mérito após o término da instrução processual. Pugnou pela liberdade provisória de ambos. Ao final, arrolou quatro testemunhas de defesa.

Na audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, e por fim, foi os réus foram interrogados.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 07/08), pelo boletim de ocorrência (pág. 69/72), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 73/74), pelo laudo de constatação provisória (pág. 45/47), pelo MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – processo número 1500440-16.2022.8.26.0659 (pág. 75/76), pelo exame químico toxicológico definitivo (pág. 112/114), com resultado positivo para THC - TETRAHIDROCANNABINOL (MACONHA) e COCAÍNA, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Das Provas Colhidas em Juízo:

Na fase policial o réu PEDRO HENRIQUE DE MOURA, assim relatou:

“Que possui advogado, que não foi agredido pelos policiais e sua família já tem ciência de sua prisão. Que tinha saído e quando voltou, se deparou com os policiais em sua residência. Que se deparou com todos algemados em sua casa, foi quando falou aos policiais, que as drogas lhe pertenciam. Quando menor, se envolveu num roubo. Que não comercializa as drogas, mas apenas as guardava para a pessoa conhecida como MAGRINHO, não sabendo onde encontrá-lo. Que RYAN estava na sua casa, apenas para cortar o cabelo” (grifei). Em Juízo, declarou que no dia dos fatos estava trabalhando na barbearia, em baixo da sua casa. O Ryan chegou para cortar o cabelo. Foi para casa da mãe ver sua filha, que estava chorando. Viu a viatura chegando. Pediu ao Ryan para falar para sua esposa jogar uma sacola que estava no banheiro. Recebeu um dinheiro para guardar as drogas, trezentos reais. Recebeu de uma pessoa de apelido magrinho. Ryan só ia cortar o cabelo, não trabalhava lá. Não é usuário de drogas.

Por sua vez, o réu RYAN MATOS SILVÉRIO, assim esclareceu na fase policial:

“Que possui advogado, que não foi agredido pelos policiais e sua família já tem ciência de sua prisão. Que havia chegado ao local para cortar o cabelo e os policiais o colocaram para dentro da casa. Que na casa estava a esposa de PEDRO. Que nada encontraram na sua posse. Que na casa encontraram drogas, que não é de sua propriedade. Que não frequenta a casa e que foi levado até à Delegacia de Polícia, porque já tem passagem por tráfico. Que já possui condenação por tráfico de drogas”. Em Juízo, declarou que estava no salão cortando o cabelo. Pedro ia cortar o cabelo e o Pedro teve que sair para ir ver a filha. O Pedro pediu para o declarante falar com a esposa dele que era pra jogar uma sacola que estava no banheiro fora. Foi abordado e os policiais acharam a droga. Não conhece os

policiais. Ia à barbearia toda semana. Trabalhava no lava car, mas não era o proprietário.

Na sequência, o policial civil LUCAS INCERPI AGENTILHO, assim consignou na fase policial:

“Que é policial civil nesta cidade e os réus estavam sendo investigados por tráfico de drogas, por isso solicitaram o mandado de busca e apreensão do local dos fatos. Que chegando ao local dos fatos com o apoio da GCM, o réu PEDRO, quando visualizou a aproximação das viaturas, empreendeu fuga numa motocicleta e o réu RYAN correu para a parte de cima do imóvel. Que correram atrás do RYAN, o qual estava ao lado de JULIANE. Que ela estava segurando uma sacola, onde encontraram vários pinos de cocaína. Questionada, afirmou que estava segurando a sacola a pedido de RYAN. Em seguida, RYAN sentou-se sobre o sofá da sala e demonstrou muito nervosismo. O mandaram se levantar e no local encontraram outros entorpecentes. Que com ajuda de um cão farejador, encontraram entorpecentes (crack e maconha) em outros locais da residência. Encontraram também notas em dinheiro. Questionado, RYAN disse que o dinheiro pertencia a PEDRO. Que PEDRO tentou passar na frente da casa, momento em que foi detido pelos policiais que estavam lá fora. Ele disse que os entorpecentes lhe pertenciam e que não era para prender as pessoas que estavam dentro da casa. Que ele tentou empreender fuga, porque estava com receio, mas foi detido. Os envolvidos foram encaminhados até à Delegacia de Polícia” (grifei). Em Juízo, declarou que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão. O Pedro e o Ryan empreenderam fuga com a chegada da viatura. Ambos foram localizados e detidos. A esposa do Pedro estava com uma sacola na mão contendo droga. O Ryan adentrou o interior do imóvel, no momento da chegada da viatura.

Após, o policial civil DIEGO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, assim relatou na fase policial:

“Que é policial civil nesta cidade e os réus estavam sendo investigados por tráfico de drogas, por isso solicitaram o mandado de busca e apreensão do local dos fatos. Que chegando ao local dos fatos com o apoio da GCM, o réu PEDRO, quando visualizou a aproximação das viaturas, empreendeu fuga numa motocicleta e o réu RYAN correu para a parte de cima do imóvel. Que correram atrás do RYAN, o qual estava ao lado de JULIANE, esposa de PEDRO. Que ela estava segurando uma sacola, onde encontraram vários pinos de cocaína. Questionada, afirmou que estava segurando a sacola a pedido de RYAN. Em seguida, RYAN sentou-se sobre o sofá da sala e demonstrou muito nervosismo. O mandaram se levantar e no local encontraram outros entorpecentes. Que com ajuda de um cão farejador, encontraram entorpecentes (crack e maconha) em outros locais da residência. Encontraram também notas em dinheiro. Questionado, RYAN disse que o dinheiro pertencia a PEDRO. Que PEDRO tentou passar na frente da casa, momento em que foi detido pelos policiais que estavam lá fora. Ele disse que os entorpecentes lhe pertenciam e que não era para prender as pessoas que estavam dentro da casa. Que ele tentou empreender fuga, porque estava com receio, mas foi detido. Os envolvidos foram encaminhados até à Delegacia de Polícia”. Em Juízo, declarou que estavam em investigação de combate ao tráfico de drogas. Foi verificado que havia um local com comércio de drogas. Foi feito, com autorização judicial, a busca e apreensão no local e encontrado drogas e dinheiro trocado. Nunca teve contato anterior com os réus. No momento que chegou com as viaturas, o Pedro estava em cima de uma motocicleta e se evadiu do local. O Ryan estava na barbearia e fugiu do local. A esposa do Pedro foi encontrada com uma sacola na mão contendo drogas. Indicou o Pedro como possuidor da droga. A barbearia era utilizada como ponto de venda de drogas. Pedro era o barbeiro que tomava conta do comércio e o Ryan era um auxiliar. O Ryan era quem “servia” no comércio de drogas. Foram encontrados mais entorpecentes, com auxílio de cão farejador, e balanças de precisão no interior da residência. No local dos fatos, efetivamente, havia a atividade de barbearia.

Dando continuidade, o guarda municipal LEANDRO JOSÉ BIDUTTI FERREIRA, assim

esclareceu na fase policial:

"Que é guarda municipal nesta cidade e juntamente com policiais civis, foram dar cumprimento a mandado de busca e apreensão do local dos fatos. Que chegando ao local dos fatos, o réu PEDRO, quando visualizou a aproximação das viaturas, empreendeu fuga numa motocicleta e o réu RYAN correu para o interior do imóvel. Que correram atrás do RYAN, o qual estava ao lado de JULIANE, esposa de PEDRO. Que ela estava segurando uma sacola, onde encontraram vários pinos de cocaína. Questionada, afirmou que estava segurando a sacola a pedido de RYAN. Em seguida, RYAN sentou-se sobre o sofá da sala e demonstrou muito nervosismo. O mandaram se levantar e no local encontraram outros entorpecentes. Que com ajuda de um cão farejador, encontraram entorpecentes (crack e maconha) em outros locais da residência. Encontraram 118 porções de cocaína, 80 porções de crack e 14 porções de maconha, além da quantia de R\$ 326,00 em dinheiro, mais R\$ 114,95 em moedas e duas balanças de precisão. A JULIANE disse que as drogas pertenciam a seu marido e ao amigo dele RYAN, e que eles sempre ficavam juntos, seja na casa ou seja na barbearia. Que ela afirmou que os dois traficavam no local. Que PEDRO tentou passar na frente da casa, momento em que foi detido pelos policiais que estavam lá fora. Ele disse que os entorpecentes lhe pertenciam e que não era para prender as pessoas que estavam dentro da casa. Que ele tentou empreender fuga, porque estava com receio, mas foi detido. Os envolvidos foram encaminhados até à Delegacia de Polícia".

Na sequência, a testemunha e esposa do réu PEDRO, MARIA JULIENE DE ALMEIDA SILVA, assim relatou na fase policial:

"Que é esposa de PEDRO. Que havia acabado de chegar do serviço e estava na cozinha de sua residência, quando o RYAN adentrou e disse que a polícia tinha acabado de prender o PEDRO. Que RYAN pediu que ela pegasse a sacola com drogas, que estava ao lado do cesto de roupas sujas no banheiro, e ela pegou. Em seguida RYAN se sentou no sofá. Que os policiais entraram e disseram que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão, momento em que ela tentou colocar a sacola sobre a mesa, mas um dos policiais abriu e viu que tinham drogas no seu interior. Que de imediato tentou explicar que a sacola com as drogas era do seu marido PEDRO e do amigo dele RYAN. Que questionada, confirmou que sabia que seu marido PEDRO comercializava drogas, e que o amigo dele RYAN ficava o dia todo com ele no salão de cabeleireiro. Que não sabe quanto tempo o seu marido comercializava os entorpecentes, mas ela não faz parte disso. Que já pediu para seu marido parar com isso, assim como o colega dele RYAN, o qual fica na casa dela, quando eles não estão no salão. Enfatiza novamente, que os entorpecentes pertenciam a PEDRO e ao RYAN" (grifei).

A testemunha de defesa, GABRIEL PEREIRA RODRIGUES, assim relatou em juízo:

"Que conhece o Pedro há 10 anos. Tem boa conduta social e familiar. Não é amigo próximo ao Ryan. Não sabe se o Pedro usa drogas. Nunca presenciou a venda de drogas na barbearia."

A testemunha de defesa, LUÍS HENRIQUE BERTONI, assim relatou em juízo:

"Que conhece o Ryan há muito tempo. Ele tem boa conduta social e familiar. Ele estava fazendo bico no lava car antes de ser preso. Conhece o Pedro da barbearia."

Do Valor e do Conjunto da Prova:

Dos Depoimentos dos Agentes de Segurança Pública:

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Face as provas colhidas nos autos, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava dividida, bem como, os depoimentos seguros prestados pelos agentes, levam à certeza de que o(s) réu(s) traficava(m) drogas na ocasião, impondo-se, pois, a condenação de ambos.

Nessa linha: "Apelação – Justiça Pública – Tráfico de Drogas – Condenação – Necessidade – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 20 pedras de crack – Depoimentos seguros e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante – Suficientes elementos para embasar a condenação – Pena – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Incidência da circunstância agravante da reincidência – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas por ausência de preenchimento dos requisitos – Imposição de Regime Fechado. Recurso de Apelação provido para condenar o réu André da Silva Ferreira à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 583 dias multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 2006, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do réu, após o trânsito em julgado." (Apelação nº 0006970-48.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas. 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: César Augusto Andrade de Castro. Julgado em 29/04/2015).

Do Crime de Tráfico:

O crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do(s) réu(s), consistente em "ter em depósito" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Restou devidamente demonstrado nos autos, que os policiais civis desta cidade já estavam investigando o local dos fatos, por fundada suspeita de tráfico de entorpecentes, quando então requereram a expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO que foi deferido (processo n.º 1500440-16.2022.8.26.0659 – pag. 75/76).

A investigação teve início com a prisão temporária de dois outros indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes, os quais confirmaram que na barbearia, de propriedade do réu PEDRO, havia intensa movimentação de tráfico de drogas, e

ainda, que tais indivíduos trabalhavam vendendo entorpecentes para o réu PEDRO. Diante de tais indícios, fora deferido o MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Os policiais civis, com o apoio da GCM, se deslocaram até o local dos fatos para dar cumprimento ao MANDADO. Quando PEDRO viu a aproximação das viaturas, montou em sua motocicleta e empreendeu fuga. O seu comparsa RYAN adentrou na residência correndo e os agentes foram atrás dele.

Dentro do imóvel encontraram a testemunha MARIA JULIANE, esposa do réu PEDRO, a qual estava com uma sacola nas mãos e o réu RYAN estava sentado em cima de um sofá. Na sacola encontraram diversos entorpecentes e embaixo do sofá, encontraram mais drogas. Com a ajuda do cão farejador da GCM encontraram diversos entorpecentes em diversos lugares do imóvel, totalizando: 80 porções de crack, 118 porções de cocaína e 14 porções de maconha, além da quantia de R\$ 326,00 em dinheiro, mais R\$ 114,95 em moedas e duas balanças de precisão, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 73/74).

A testemunha MARIA JULIANE explicou que RYAN havia adentrado na residência, dizendo que policiais haviam prendido o marido dela PEDRO, e a mandou pegar a sacola com drogas, que estava ao lado do cesto de roupas sujas do banheiro. Sem pensar muito, ela acabou pegando a sacola, quando os policiais adentraram na sua residência. Afirmou a testemunha, que sabia que seu marido vendia entorpecentes e já tinha pedido pra ele parar com aquilo, e ainda, que RYAN estava trabalhando com ele, e ficavam lá na barbearia o dia todo. Por fim, relatou que ela não tem envolvimento com o tráfico e que as drogas são de seu marido PEDRO e do colega dele RYAN, os quais trabalham juntos na mercancia dos entorpecentes.

Enquanto todos estavam na residência, depois de algum tempo, o réu PEDRO tentou passar na frente do local, para saber como estavam as coisas, quando então foi reconhecido e parado pelos policiais. Ele então afirmou que os entorpecentes lhe pertenciam, e que ninguém da casa era para ser preso no lugar dele.

Formalmente, na fase policial, o réu RYAN negou a prática do delito, dizendo que estava no local apenas para cortar o cabelo. Em Juízo, ratificou sua versão.

Por sua vez, o réu PEDRO negou a mercancia dos entorpecentes, mas afirmou que guardava as drogas para terceiro, o qual não quis qualificar. Disse ainda, que RYAN estava no local apenas para cortar o cabelo. Em Juízo, ratificou tal versão.

Em que pese o quanto argumentado pelos réus, restou mais do que demonstrado, que ambos trabalhavam em conjunto na mercancia dos entorpecentes. Como esclarecido pela própria esposa do réu PEDRO, eles ficavam juntos o dia todo na barbearia e na residência da família, local em que também encontraram as balanças de precisão. Além disso, a investigação trouxe de forma evidente os indícios de traficância que foi devidamente comprovado no dia da prisão.

Vale ainda consignar, que não há motivos para se duvidar das palavras dos policiais civis e do guarda municipal, que nem ao menos conheciam os réus, e não teriam qualquer motivo para incriminá-los. Portanto, cabia aos réus provar versão contrária, fato do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Verifico ainda, que o artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 traz dezoito núcleos para a caracterização do tipo penal, e qualquer deles é mais do que o suficiente para a caracterização do delito.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante do exposto, a condenação dos réus é medida que se impõe, nos termos do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

De se alinhar que não se há falar em quantidade ínfima de droga.

Crime de Associação para o Tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006):

Os réus também foram denunciados como incurso no artigo 35, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de que teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Assim disciplina o artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Este juízo adota o entendimento de que o delito tipificado no artigo 35 da Lei Antidrogas é autônomo, ou seja, constitui em soldado de reserva da ordem jurídica, aplicável, pois, cumulativamente ao artigo 33 da mesma lei, pelo qual o acusado já fora aqui condenado.

Nessa linha é o entendimento consolidado do STJ, vejamos:

"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APROFUNDADA INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. CONSUNÇÃO PELO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA. CRIMES AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REINCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA." (HC 200996 SP 2011/0060847-9. Relator(a): Ministro GILSON DIPP. Julgamento: 16/08/2012. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Publicação: DJe 22/08/2012).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI DE DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não configura "bis in idem" a incidência da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06 aos delitos de associação - previsto no art. 35, da Lei de Drogas -, porquanto a associação para o tráfico é crime autônomo, que deve ser punido de forma mais severa quando visar o tráfico internacional de entorpecentes 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no RESp 1406905 MG 2013/0323953-0. Relator(a): Ministro MOURA RIBEIRO. Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Publicação: DJe 07/03/2014).

Pois bem.

Como já salientado, restou devidamente demonstrado nos autos, que os policiais civis desta cidade já estavam investigando o local dos fatos, por fundada suspeita de tráfico de entorpecentes, quando então foi deferido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO (processo n.º 1500440-16.2022.8.26.0659 - pág. 75/76).

A investigação teve início com a prisão temporária de dois outros indivíduos

envolvidos com o tráfico de entorpecentes, os quais confirmaram que na barbearia, de propriedade do réu PEDRO, havia intensa movimentação de tráfico de drogas, e ainda, que tais indivíduos trabalhavam vendendo entorpecentes para o réu PEDRO. Diante de tais indícios, fora deferido o MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Os policiais civis, com o apoio da GCM, se deslocaram até o local dos fatos para dar cumprimento ao MANDADO. Quando PEDRO viu a aproximação das viaturas, montou em sua motocicleta e empreendeu fuga. O seu comparsa RYAN adentrou na residência correndo e os agentes foram atrás dele.

Dentro do imóvel encontraram a testemunha MARIA JULIANE, esposa do réu PEDRO, a qual estava com uma sacola nas mãos e o réu RYAN estava sentado em cima de um sofá. Na sacola encontraram diversos entorpecentes e embaixo do sofá, encontraram mais drogas. Com a ajuda do cão farejador da GCM encontraram diversos entorpecentes em diversos lugares do imóvel, totalizando: 80 porções de crack, 118 porções de cocaína e 14 porções de maconha, além da quantia de R\$ 326,00 em dinheiro, mais R\$ 114,95 em moedas e duas balanças de precisão, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 73/74).

A testemunha MARIA JULIANE explicou que RYAN havia adentrado na residência, dizendo que policiais haviam prendido o marido dela PEDRO, e a mandou pegar a sacola com drogas, que estava ao lado do cesto de roupas sujas do banheiro. Sem pensar muito, ela acabou pegando a sacola, quando os policiais adentraram na sua residência. Afirmou a testemunha, que sabia que seu marido vendia entorpecentes e já tinha pedido pra ele parar com aquilo, e ainda, que RYAN estava trabalhando com ele, e ficavam lá na barbearia o dia todo. Por fim, relatou que ela não tem envolvimento com o tráfico e que as drogas são de seu marido PEDRO e do colega dele RYAN, os quais trabalham juntos na mercancia dos entorpecentes.

Enquanto todos estavam na residência, depois de algum tempo, o réu PEDRO tentou passar na frente do local, para saber como estavam as coisas, quando então foi reconhecido e parado pelos policiais. Ele então afirmou que os entorpecentes lhe pertenciam, e que ninguém da casa era para ser preso no lugar dele.

Formalmente, na fase policial, o réu RYAN negou a prática do delito, dizendo que estava no local apenas para cortar o cabelo. E, em juízo, ratificou sua versão.

Por sua vez, ainda na fase policial, o réu PEDRO negou a mercancia dos entorpecentes, mas afirmou que guardava as drogas para terceiro, o qual não quis qualificar. Disse ainda, que RYAN estava no local apenas para cortar o cabelo. Em Juízo, ratificou sua versão. Disse que começou a traficar por conta do pós pandemia, pois estava devendo dinheiro e, por isso, aceitou ficar com a droga.

Em que pese o quanto argumentado pelos réus, restou mais do que demonstrado, que ambos trabalhavam em conjunto na mercancia dos entorpecentes. Como esclarecido pela própria esposa do réu PEDRO, na fase policial, eles ficavam juntos o dia todo na barbearia e na residência da família, local em que também encontraram as balanças de precisão.

Assim, unindo a investigação policial, os depoimentos seguros dos policiais civis prestados nesta data, os depoimentos do guarda municipal e da esposa de Pedro na fase policial, somado à forma como se deu o flagrante, demonstrando claro envolvimento entre os réus, não há que se falar em absolvição pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Não há dúvidas sobre a prévia associação entre os réus para o sucesso da empreitada criminosa.

Nessa mesma esteira, colaciono as decisões dos Tribunais:

"Apelação. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição. Defesas que pretendem a absolvição dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 ou a desclassificação para o tipo descrito no artigo 28, da referida Lei de Drogas (em relação ao corréu Leonardo). Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus por tráfico e associação para o tráfico. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do referido diploma legal. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, aliadas à caracterização do crime de associação que inviabilizam a concessão da benesse. Insuficiência probatória no tocante ao crime de posse irregular de munição em relação aos corréus Leonardo e Elielson. Penas que comportam reparo. Regime prisional bem justificado. Quantidade de pena aplicada que afasta a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos defensivos parcialmente providos para absolver os réus Leonardo e Elielson quanto ao crime descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 e redimensionar as penas de todos os acusados." (Apelação nº 0009903-30.2013.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá. 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Sérgio Coelho. Julgado em 03/12/2015).

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito e, diante desse seguro quadro probatório, a condenação dos réus é a solução adequada.

Passo a Dosar as Penas:

Réu PEDRO HENRIQUE DE MOURA:

Do Crime de Tráfico:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu é tecnicamente primário (pág. 152/153). Contudo, é de se observar que ele mantinha em depósito, considerável quantidade e variedade de entorpecentes (118 porções de cocaína, 80 porções de crack e 14 porções de maconha), o que demonstra a maior gravidade em sua conduta, face a natureza e nocividade do crack e cocaína motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/6, resultando em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Neste sentido, destaco o que já decidiu o ETJSP na Apelação 1500465.33.2022.8.26.0302, Relator Fátima Vilas Boas Cruz, j. 20/09/2022. 4ª Câmara de Direito Criminal:

"Ementa: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Provas de materialidade e autoria – Condenação mantida – Pena base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza e diversidade da droga apreendida em poder do acusado – Possibilidade – Comprovada dedicação do réu às atividades ilícitas – Segunda fase- Compensada a reincidência com a confissão do réu, o que se mostrou favorável a este, tendo em vista que a reincidência, ainda mais específica, é circunstância preponderante – Mantido o regime inicial fechado ante as circunstâncias do presente caso concreto, pelo fato do réu se dedicar à mercancia e em virtude do crime de tráfico ser equiparado a crime hediondo -- Inviável a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos porque o acusado não preenche os requisitos exigidos no artigo 44 do Código Penal para concessão da benesse – RECURSO IMPROVIDO."

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes agravantes ou atenuantes. Anoto que o réu não confessou a prática do crime, já que apenas trouxe, nas suas próprias palavras, sua versão e, tentou eximir o co-requerido da prática do crime.

Na terceira fase de aplicação da pena, considerando que restou demonstrado nos autos que o réu se associou com outro indivíduo para o tráfico de entorpecentes, bem como, considerando a natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas (118 porções de cocaína, 80 porções de crack e 14 porções de maconha), demonstrando seu envolvimento com organização criminosa, não vislumbro ser o caso de aplicação do privilégio, motivo pelo qual deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, esta pena torna-se definitiva.

Do Crime de Associação:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu é tecnicamente primário (pág. 152/153). As demais circunstâncias judiciais são punidas pela própria tipicidade do delito, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas, ainda mais no caso em tela, que o réu também se associou com outra pessoa. Além disso, cuida-se de delito equiparado a hediondo, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente FECHADO, como expressamente previsto no artigo 2º, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07.

Outrossim, as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas, "maconha", "cocaína" e "crack", se desse modo que ele conseguia o seu sustento, certo que a "cocaína" e o "crack" são os tipos de substâncias entorpecentes que reclamam, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelo réu, razão que se impõe, mesmo, o regime prisional mais gravoso. Não bastasse, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem do réu estão a impor, ainda com maior razão, o regime prisional fechado, não se perdendo de vista a correlação entre o art. 59, "caput" e o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal.

Não se faz presente a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, porque tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

Acerca da constitucionalidade da vedação à conversão da pena privativa de liberdade em sanção alternativa, nesse sentido, aliás, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, ponderando que embora tenha o Supremo Tribunal Federal afirmado ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, rel. Min. Ayres Brito), deve ser ressalvado que tal decisão foi adotada em sede difusa, por maioria de votos e sem efeito vinculante (cf. HC 168.459/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/10).

Ressalto que o delito em questão, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros crimes tão ou mais graves e intimamente ligados

com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias.

Portanto, para ambos os delitos: TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei n. 11.343/06, sendo fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos que pudesse majorar tal pena.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Réu RYAN MATOS SILVÉRIO:

Do Crime de Tráfico:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu é REINCIDENTE (pág. 158/159), fato que será considerado na segunda fase de aplicação da pena. Contudo, é de se observar que ele mantinha em depósito, considerável quantidade e variedade de entorpecentes (118 porções de cocaína, 80 porções de crack e 14 porções de maconha), o que demonstra a maior gravidade em sua conduta, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/6, resultando em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a atenuante da MENORIDADE e a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 158/159), tendo em vista que o réu foi condenado por tráfico de entorpecentes, que tramitou perante a 3ª Vara Judicial de Vinhedo, sob o número 1502458-35.2020.8.26.0544 e transitou em julgado para a defesa em 11/08/2021, o que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO, fato que agrava ainda mais a situação. Razão pela qual, considerando a reincidência específica e a menoridade, majoro a pena em 1/6, resultando na pena de: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que “atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo”. Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que “a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica”.

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, “na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza”.

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada”. (HC 101918/MS – Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)”.

Nesse sentido:

MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inoportunidade no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como a apreensão das drogas em posse dos réus; a tentativa de empreender fuga em conhecido ponto de venda de drogas; dão a necessária certeza de que a droga destinava-se ao comércio espúrio tipo congruente. PENA primeira fase pena-base majorada em 2/5 ante a natureza da droga apreendida manutenção segunda fase aplicada a agravante da reincidência específica, aumentando a pena em 1/3 -

manutenção - não há atenuantes terceira fase não há causas de aumento inaplicável o redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ante a reincidência do réu. REGIME fechado réu reincidente específico regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa negado provimento. (Apelação n.º 0011580-72.2017.8.26.0635 – 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Relator: Laudo Mens de Mello – Julgamento: 28/02/2019).

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Na terceira fase de aplicação da pena, considerando que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO (pág. 158/159), e ainda, que restou demonstrado nos autos que ele se associou com outro indivíduo para o tráfico de entorpecentes, bem como, considerando a natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas (118 porções de cocaína, 80 porções de crack e 14 porções de maconha), demonstrando seu envolvimento com organização criminosa, não vislumbro ser o caso de aplicação do privilégio, motivo pelo qual deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, esta pena torna-se definitiva.

Do Crime de Associação:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu é reincidente (pág. 158/159), fato que será considerado na segunda fase de aplicação da pena. As demais circunstâncias judiciais são punidas pela própria tipicidade do delito, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a atenuante da MENORIDADE e a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 158/159), tendo em vista que o réu foi condenado por tráfico de entorpecentes, que tramitou perante a 3ª Vara Judicial de Vinhedo, sob o número 1502458-35.2020.8.26.0544 e transitou em julgado para a defesa em 11/08/2021, razão pela qual compenso ambas e mantenho a pena acima aplicada.

Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Apesar do quanto disposto pela D. Defesa, o réu é REINCIDENTE (pág. 158/159). Além disso, o tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas, ainda mais no caso em tela, que o réu também se associou com outra pessoa. Ademais, cuida-se de delito equiparado a hediondo, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente FECHADO, como expressamente previsto no artigo 2º, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07.

Outrossim, as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas, "maconha", "cocaína" e "crack", se desse modo que ele conseguia o seu sustento, certo que a "cocaína" e o "crack" são os tipos de substâncias entorpecentes que reclamam, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelo réu, razão que se impõe, mesmo, o regime prisional mais gravoso. Não bastasse, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas e as circunstâncias da

abordagem do réu estão a impor, ainda com maior razão, o regime prisional fechado, não se perdendo de vista a correlação entre o art. 59, "caput" e o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal.

Não se faz presente a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, porque tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

Acerca da constitucionalidade da vedação à conversão da pena privativa de liberdade em sanção alternativa, nesse sentido, aliás, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, ponderando que embora tenha o Supremo Tribunal Federal afirmado ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, rel. Min. Ayres Brito), deve ser ressalvado que tal decisão foi adotada em sede difusa, por maioria de votos e sem efeito vinculante (cf. HC 168.459/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/10).

Ressalto que o delito em questão, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros crimes tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias.

Portanto, para ambos os delitos: TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO.

De se alinhar que, respeitado os astutos argumentos da D. Defesa, não cabe discutir nestes autos a questão do sistema carcerário/prisional do Brasil.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei n. 11.343/06, sendo fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos que pudesse majorar tal pena.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de PEDRO HENRIQUE DE MOURA, já devidamente qualificado, para o fim de:

a) CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06;

b) CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Os crimes se deram na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Assim como, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de RYAN MATOS SILVÉRIO, já devidamente qualificado, para o fim de:

a) CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06;

b) CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Os crimes se deram na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Da Prisão Preventiva:

Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação